

《【문제3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음2) 乙이 판사 B에 대하여 제기하려는 기피신청의 원인인 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 기준과 기피신청 시 소송절차의 정지 여부에 대하여 설명하시오.》

<문제3.2의 물음2> 기피원인인 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 기준과 기피신청 시 소송절차의 정지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 항소심 재판부의 판사 B가 원고 甲과 고등학교 동창이고 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀져 乙이 재판의 공정성을 이유로 기피신청을 하려는 상황이다. 쟁점으로 <민사소송법상 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 판단기준과 기피신청이 제기된 경우 소송절차의 정지 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판사 B에 대한 기피사유의 인정 여부와 기피신청에 따른 소송절차의 효력에 대해 설명한다.

II. 기피원인 : 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정

1. 의의 및 판례의 객관적 기준

(1) 의의

- 민사소송법 제43조 제1항은 법관에게 공정한 재판을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 기피신청을 할 수 있다고 규정한다.

(2) 객관적 기준에 관한 판례의 태도★

- 판례는 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이란 당사자가 주관적으로 불신감을 갖는 것만으로는 부족하고, 통상인의 판단에 의하더라도 법관이 편파적인 재판을 할 것이라는 의심을 가질 만한 객관적인 사정이 있는 경우를 의미한다고 본다. 즉, 법관과 당사자의 친분 관계, 원한 관계, 법관이 해당 사건의 승패에 직접적인 이해관계를 가졌다고 보일 만한 외관이 존재해야 한다.

2. 사안의 경우

- 판사 B가 원고 甲과 고교 동창이라는 사실이나 경조사에 참여하여 축의금을 전달한 사실은 한국 사회의 통상적인 사교례에 해당할 수 있다. 그러나 그 친분의 정도가 단순한 지인을 넘어 각별하여 재판 결과에 영향을 미칠 정도라면 객관적 기피사유가 될 수 있다. 다만, 실무상 단순한 동창 관계만으로는 기피신청이 인용되기 어려우며, 구체적으로 불공정한 재판 진행이 동반되어야 기피의 객관적 타당성이 인정될 것이다.

III. 기피신청과 소송절차의 정지

1. 원칙 : 소송절차의 정지

- 민사소송법 제48조 본문에 의하면 법원은 기피신청이 있는 경우 기피신청에 대한 재판이 확정될 때까지 소송절차를 정지하여야 한다. 이는 불공정한 재판을 받을 위험이 있는 상태에서 소송이 강행되는 것을 방지하기 위함이다. 정지되는 절차는 해당 기피 법관이 관여하는 모든 소송행위를 포함한다.

2. 예외 : 소송절차를 정지하지 않는 경우

- 소송의 지연을 목적으로 하는 무분별한 기피신청으로부터 재판의 효율성을 보호하기 위해 다음과 같은 예외를 둔다.

(1) 기피신청의 각하[민소법 제45조 제1항]

- 기피신청이 신청권을 남용하는 것이 명백하거나, 기합의된 기피신청 방식에 어긋나는 경우 등 요건을 갖추지 못한 때에는 원심법원이 결정으로 이를 각하할 수 있으며, 이 경우에는 절차를 정지하지 않는다.

(2) 종국판결의 선고

- 판례와 통설에 의하면, 변론이 종결된 후 판결만을 선고하는 단계에서는 기피신청이 있더라도 소송절차를 정지하지 않고 판결을 선고할 수 있다.

(3) 긴급을 요하는 행위

- 증거인멸의 우려가 있거나 기일을 늦출 경우 당사자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있는 긴급한 행위는 절차 정지 중에도 예외적으로 허용된다.

IV. 절차 정지 위반의 효력

1. 절차 위반의 원칙적 효력

- 소송절차 정지 규정을 위반하여 진행된 소송행위는 원칙적으로 무효다. 따라서 기피신청 중 정지하지 않고 진행한 변론이나 증거조사 등은 효력이 없다.

2. 하자의 치유

- 기피신청이 최종적으로 기각 확정된 경우에는 절차 정지 규정을 위반하여 행한 소송행위라도 그 하자가 치유되어 유효한 것으로 간주된다. 이는 기결정된 기각 재판을 존중하여 소송 경제를 도모하기 위함이다.

V. 결론

- 乙이 판사 B에 대하여 제기하려는 기피신청은 통상인의 관점에서 공정성을 의심할 만한 객관적 사정이 입증되어야 한다. 기피신청이 접수되면 법원은 원칙적으로 소송절차를 정지해야 하며, 예외적으로 신청이 명백히 부적법하여 각하되는 경우나 긴급한 행위 등이 아닌 한 재판을 계속해서 안 된

다. 만약, 법원이 절차를 정지하지 않고 재판을 강행하였으나 이후 기피신청이 기각된다면 그 소송행위의 하자는 치유되나, 기피신청이 인용된다면 해당 소송행위는 무효가 된다.